

1500028-66.2022.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DE PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GUILHERME HENRIQUE DE PAULO, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

1500028-66.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500028-66.2022.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DE PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GUILHERME HENRIQUE DE PAULO, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 13h19, na Avenida Brasil, nº 446, Balneário Flórida Mirim, nas imediações do Centro de Progressão Penal, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e venda de terceiros, 62 porções de cocaína, com peso total bruto de 74g, e 20 porções de cocaína, com peso total bruto de 52g, conforme auto de Exibição/Apreensão de fls. 10/11 e Auto Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 13.

Narra que o acusado, querendo praticar a comercialização ilícita de entorpecentes, embarcou no veículo de transporte por aplicativo de propriedade de Diogo Furili (marca/modelo Ford/KA, ano 2017/2018, placa QNA1E83) em direção ao Centro de Progressão Penal de Mongaguá, trazendo consigo as supramencionadas drogas. Ocorre

que policiais militares que realizavam o patrulhamento no local dos fatos em razão da saída temporária de vários presos, notaram que o passageiro do referido veículo demonstrou certo nervosismo com a aproximação policial, razão pela qual decidiram pela abordagem. Junto ao vestuário de GUILHERME foram encontradas 10 (dez) porções de cocaína, sendo que na sacola plástica que trazia ao seu lado foram encontrados o restante das drogas, além de dois aparelhos celulares. Informalmente, o acusado admitiu que pretendia ingerir as drogas e depois de expeli-las, comercializadas no interior do Estabelecimento Prisional. Assim, a quantidade de drogas, o local do fato e as atitudes do denunciado, a apreensão de certa quantia de origem não esclarecida, bem como as demais circunstâncias da abordagem indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo e venda a terceiros.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 71/72).

A denúncia foi recebida (fls. 102/104) e o réu, citado (fls. 131), apresentou resposta à acusação (fls. 111/112).

Laudo de constatação a fls. 13 e laudo toxicológico definitivo a fls. 135/137.

Em audiência foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado confessa ter trazido a droga, dizendo que recebeu ligação de sua genitora e ficou sabendo que ela precisava de dinheiro para custear seu tratamento de saúde, tendo aceitado servir de mula para outro preso para levantar recursos.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, fixação da pena acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga, agravamento da pena em razão da multirreincidência específica, mas sem a causa de aumento de pena diante da insuficiência probatória a seu respeito; e a defesa técnica, pelo afastamento da causa de aumento e consideração da confissão. Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 55/61.

Fundamentação

Materialidade e Autoria

A materialidade da ação criminosa restou demonstrada pelas provas documental, pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de cloreto de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercílio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP,

2010).

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, as testemunhas ouvidas atestaram ter sido o acusado abordado em veículo de transporte privado quando se dirigia à unidade prisional levando consigo, inclusive no interior de seu corpo, as drogas.

Wesley disse que viu atitude suspeita de indivíduo no interior do veículo que passou por um ponto de monitoração da volta da saída de fim de ano. Em busca pessoal e no veículo, localizou a droga que seria ingerida por Guilherme para adentrar a Cadeia de Mongaguá. Guilherme confessou que já havia ingerido algumas substâncias.

O policial Marcos disse que estava em operação de retorno dos reeducandos ao presídio, pela Avenida Brasil, quando visualizaram um veículo estacionado com dois ocupantes, um do banco do motorista e outro no traseiro. O passageiro apresentou nervosismo, o que ensejou a abordagem. Com o condutor nada foi localizado, mas com GUILHERME localizaram papelotes de cocaína. Em busca veicular, sob o banco, encontraram mais papelotes e eppendorf, embalagens plásticas e porções de maconha e aparelho celular. Informalmente GUILHERME confessou que iria ingerir a droga para adentrar a unidade prisional e o motorista disse que era uber contratado por GUILHERME e mais dois indivíduos. Depois da delegacia, levaram GUILHERME à UPA e lá constataram papelotes já ingeridos, que vieram a ser expelidos após período de observação. No momento da abordagem, estavam na avenida do CPP, mas ainda estavam longe, cerca de 1,5km.

Diogo disse que estava no taxi e recebeu pedido de uber para levar até o CPP de Mongaguá. Subiu na rodoviária e havia três ocupantes, que racharam a corrida.

Chegando no CPP, a viatura policial fez a abordagem e encontrou droga com GUILHERME. Não conhecia o acusado. Os dois desceram e GUILHERME estava descendo do veículo quando a força tática chegou. Estavam a cerca de 50 a 100 metros da unidade prisional.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão espontânea em juízo.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar tenha sido a infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, razão pela qual inaplicável a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Deixo de valorar os maus antecedentes, não recepcionada a valoração de inquéritos ou processos sem trânsito em julgado pela presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal,

neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa. Não veio aos autos elemento probatório seguro de especial necessidade financeira do acusado, para custear tratamento de saúde de sua genitora, a indicar menor reprovabilidade.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são pequenas, conforme atestado pelo laudo pericial, e autorizam um juízo favorável ao acusado, pois inferiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados.

Por tudo isto, considerado favoráveis a conduta social e a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal). Deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem.

Por conseguinte, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, que é reduzida para o mínimo de 5 anos.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, fixo a pena de multa final em 500 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, bem assim do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar GUILHERME HENRIQUE DE PAULO à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, e a 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Prisão preventiva

Nos termos do art. 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistema de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Ainda com o trânsito em julgado, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

P. I. C.

Mongaguá, 08 de maio de 2022.